主題：法律行為-意思表示[1]

壹、概論

意思表示	客觀要素	表示行為	表意人外觀上有足以使人認為其在表示某種法律效果意思的行為	必要要素
	主觀要素	行為意思	表意人就其外部從事的表示行為，內心具有自覺或認識	必要要素
		表示意思	表意人內心意識其表示行為具有某種法律意義、得發生某種法律效果的意思	有爭議 ➢ 學說：並非必要要素 ➢ 陳聰富：為必要要素
		效果意思	表意人內心有依其表示行為發生特定法律效果的意思	並非必要要素

意思表示形成、傳遞 此部分主要處理錯誤、詐欺、脅迫等問題
↓
意思表示成立 此部分主要處理意思表示構成要素欠缺的效力等問題
↓
意思表示生效 此部分主要處理何謂送達、非完全行為能力人等問題
↓
意思表示合致（法律行為成立） 此部分主要處理意思表示是否合致等問題
↓
法律行為生效 此部分主要處理民法第 71、72、246 條或要式、物行為等問題

所謂的**意思表示，係指表意人將其內心上期望發生某種法律效果之意思，表示於外部之行為**[2]。而法律行為與意思表示之區分有其困難之處，尤其是單獨行為。是以，姑且可以理解為意思表示為手段，法律行為為目的[3]。

貳、要件

在討論意思表示之構成要素前，首先需要理解並非欠缺下列其一，意思表

[1] 此課輔講義大量參酌顏佑紘老師 114-1 開設的民法總則上課講義，有援引之處不一一列舉。
[2] 陳聰富，民法總則，4 版，頁 207，2022 年。
[3] 陳自強，民法總則法律行為—民法講義 I，5 版，頁 39，2023 年。

示即會不成立，下列要素僅是理想上健全的意思表示所應具備的要件，然而並不等於意思表示會不成立[4]，而是需要討論個別要件欠缺後之效果為何。至於欠缺要件而是否要使其成立，涉及意思自主與信賴保護之衝突。

一、表示行為

所謂**「表示行為」，係指表意人外觀上有足以使人認為其在表示某種法律效果意思的行為**。例如：於房地買賣契約書上簽名的行為。此一要素，屬意思表示的客觀要素[5]，此為意思表示之必要要素，並無疑義[6]。

二、行為意思

所謂**行為意思，即表意人就其外部從事的表示行為，內心具有自覺或認識**。須注意者，受脅迫者仍有行為意思，然處於意思表示不自由之狀態，而導致有瑕疵，兩者概念不同，應予區辨[7]。例如：

案例：甲受黑道大哥乙抓著手臂強制在出售房地產的契約上用印

通說上認為，**基於對當事人之意思自主之最低尊重**，若當事人根本無行為意思，亦不應使其受拘束，**而為意思表示之必要要素**[8]。

三、表示意思

所謂**表示意思，指表意人內心意識其表示行為具有某種法律意義、得發生某種法律效果的意思**[9]。須注意者，表意人僅需知悉表示行為有某種法律意義即可，無須特定到何種法律效果之程度。

然而欠缺表示意思是否會使得意思表示不發生效果，學說上爭議頗大：

案例：甲在拍賣會場舉手招呼友人，結果被認為應買，甲舉手之意思表示是否發生效力？

此案中，甲之行為在交易習慣可認為默示之意思表示，然甲當下並沒

[4] 換言之，下述四個要件僅是「構成要素」，與欠缺後會失效的「必要要素」並不相同
[5] 陳忠五，意思表示「不成立」與意思表示「有瑕疵」的區別－最高法院 109 年度台上字第 1431 號判決簡析，台灣法律人，1 期，頁 159，2021 年。
[6] 王澤鑑，民法總則，增補新版，頁 429，2024 年。
[7] 陳自強，註 3，頁 252、253。
[8] 陳忠五，註 14，頁 159；通說可參考陳聰富，當事人的締約意思──效果意思或表示意思，月旦法學雜誌，327 卷 327 期，頁 80，2022 年；類似見解可參考陳自強，註 8，頁 252、253。然而應該注意的是陳忠五老師認為此時應該是意思表示「不成立」，而陳自強老師認為應該是適用民法第 75 條而使得意思表示「無效」，效果可說完全沒有差別。
[9] 陳忠五，註 5，頁 159；王澤鑑，註 6，頁 428。須注意者，表示意思亦有定義為：有使存於內部之效力意思與其表現於外部之行為相聯絡之意思（參最高法院 101 年度台上字第 1025 號民事判決），若依照實務見解之定義，如甲將賣出 A 屋之信件寫好後放在抽屜內未寄出，亦未有表示意思，然而此亦涉及意思表示是否發出之問題。

有認識到其拍賣會場舉手有發生某種法律效果之意思，**此時即欠缺表示意思，此時甲之意思表示仍生效**[10]？

陳忠五老師認為表示意思並非必要要件，**表意人內心是否有表示意思，相對人難以查證，因此基於交易安全之保護，應該認為表示意思並非必要要件**，意思表示仍生效力，表意人僅得以錯誤規定撤銷[11]。

陳聰富老師認為，**表示意思仍為意思表示之必要要件**，若有欠缺則不生效力，**否則無法解釋為何好意施惠行為不生拘束效力**，惟意思表示是否具備表示意思，則應客觀解釋意思表示，**自理性第三人的客觀判斷，表意人之行為足以令相對人信賴其認識將發生某種法律效果，此時即應承認表意人具有表示意思**，如此即可解決交易安全不受保障的問題[12]。

如果覺得陳聰富老師的見解很難理解的話，舉一例說明：

案例：甲和乙共進晚餐，乙詢問甲是否可以開車帶乙回家，甲基於紳士風度，便一口答應。

此為好意施惠之行為的常見案例，在此情況下通常認為甲答應之行為並無法律上的拘束力[13]，其原因便是在於甲、乙在當下的脈絡並不會認為該對答具有法律上的意義，而欠缺表示意思，然而若按照陳忠五老師的見解，便會造成此時好意施惠行為即便欠缺表示意思，而仍有法律上之拘束力。

四、效果意思

效果意思係指表意人內心有依其表示行為發生特定法律效果的意思，例如，內心有簽名於契約書使之發生房地買賣權利義務的意思[14]。

應該注意的是，效果意思與表示意思並不相同，前者，係以發生「特定」法律效果為必要，後者，僅需認識到具有某種法律意義即可。因此可以推論出，具有效果意思者，通常具有表示意思，檢討順序上應該先確定有表示意思再確定有效果意思。

---

[10] 下面的各位老師的學說分類可能跟陳聰富老師文章中的不太一樣，建議還是以老師的見解為準。

[11] 陳忠五，註 5，頁 162；王澤鑑，註 6，頁 429、430。應該注意者王澤鑑老師主張此時應該要類推適用錯誤之規定撤銷。

[12] 陳聰富，註 8，頁 83–89；陳自強，註 3，頁 254、255。

[13] 不然在這種情況下甲還要負擔債務不履行的責任也太可怕了吧這個社會……。

[14] 陳忠五，註 5，頁 159。

有疑問者，效果意思是否為意思表示之必要要素？舉最高法院 109 年度台上字第 1759 號民事判決[15]事實為例：

案例：藝術家甲創作五百多幅作品，遭 A 公司放在網路上供他人下載或使用，甲認為 A 公司侵害其著作權，A 公司抗辯 A 公司負責人乙於甲參加 A 之作品展覽時，有拿其同意在網路上使用的授權書給甲簽名，甲則再抗辯當下其簽名是因為誤認為該授權書簽名僅是對於該次展覽的授權所以才會簽名，對於後續的授權並無同意。

本件應如何處理？討論如下：

延伸討論：效果意思是否為意思表示之必要要素？

通說採否定見解認為，**效果意思相對人難以察覺，因此為了保障交易安全，故並非必要要素**，若當事人有欠缺效果意思的情況，**僅係有錯誤得撤銷或是通謀虛偽無效之效果**[16]。

然而實務亦有判決採取肯定見解，認為欠缺效果意思，該意思表示即不成立[17]。

本件甲對於授權書包含供網路上使用同意之特定法律效果並無認識，是以，欠缺效果意思，若採取肯定說者，此時意思表示仍成立生效，僅是甲得否可依錯誤撤銷的問題；若採取前述的否定說者，則無法成立[18]。

肯否兩說究竟以何說可採，應採肯定說，最高法院之所以透過此種解釋的方式僅為了避免當事人因為錯誤撤銷權罹於民法第 90 條的一年除斥期間，而在個案上對於欠缺效果意思之當事人顯失公平。

然而實際上陳忠五老師認為，可以擴大相對人之告知義務，在相對人明知表意人有錯誤的情況下，依照誠實信用原則，應該告知相對人該錯誤之情事並確認表意人之真義為何，否則構成民法第 92 條之詐欺[19]。透過此種方法，可以緩和上述對於肯定說的疑慮。

---

[15] 該案件目前仍繫屬於最高法院審理中。

[16] 陳忠五，註 5，頁 161；陳聰富，註 8，頁 81、82；王澤鑑，註 6，頁 429；陳自強，註 3，頁 253。

[17] 「按法律行為以意思表示為基礎，意思表示由效果意思、表示意思及表示行為三要素構成；效果意思，係指表意人期以發生一定法律效果之內部主觀意思，表意人所為欠缺效果意思之表示，難認已為意思表示。」最高法院 109 年度台上字第 1431 號民事判決參照。應該注意的是，該判決下當事人已經錯過錯誤撤銷之期間，最高法院逼不得已才會透過此種解釋方法避免當事人無法救濟。

[18] 應該注意的是，本則裁判認定本件意思表示仍然成立生效，是以，前述否定說並非實務之穩定見解。

[19] 陳忠五，再論意思表示「不成立」與意思表示「有瑕疵」的區別－最高法院 109 年度台上字

參、意思表示之到達

民法第 94 條
對話人為意思表示者，其意思表示，以相對人了解時，發生效力。
民法第 95 條
I. 非對話而為意思表示者，其意思表示，以通知達到相對人時，發生效力。但撤回之通知，同時或先時到達者，不在此限。
II. 表意人於發出通知後死亡或喪失行為能力或其行為能力受限制者，其意思表示，不因之失其效力。
民法第 96 條
向無行為能力人或限制行為能力人為意思表示者，以其通知達到其法定代理人時，發生效力。
民法第 97 條
表意人非因自己之過失，不知相對人之姓名、居所者，得依民事訴訟法公示送達之規定，以公示送達為意思表示之通知。

意思表示之生效，區分對話與非對話意思表示而做不同規定，對話意思表示，係以相對人了解時發生效力；非對話意思表示則係以意思表示到達相對人時發生效力。

而所謂的達到，乃指**意思表示已經置於相對人可能支配之範圍，置於相對人居於隨時可了解其內容之地位的客觀狀態**[20]。

上述以圖表整理如下：

對話	相對人了解時，發生效力	
非對話	通知達到相對人時	發生效力
		若撤回先或同時到達，不生效力

而非完全行為能力人，因為其原則上無法獨立為法律行為，因此以接受或發出法律行為時判斷其行為能力，若非完全行為能力人，則由法定代理人代為或代受意思表示。

較有爭議者：書面郵寄掛號，郵務機關因不獲會晤相對人，而製作招領通知單是否發生意思表示發生效力？

第 1066 號判決（機關簽署採購契約書案）及第 1759 號判決（藝術家簽署授權同意書案）簡析，台灣法律人，2 期，頁 181、182，2021 年。

[20] 陳聰富，註 2，頁 218；王澤鑑，註 6，頁 439；陳自強，註 3，頁 54。

延伸討論：最高法院 109 年度台上大字第 908 號民事裁定[21]

大法庭採取肯定說**認為相對人受招領通知時，表意人之意思表示已到達相對人而發生效力，不以相對人實際領取為必要**，理由有二：1.依一般社會觀念可期待相對人受通知後，於郵局營業時間前往領取郵件，該郵件置於相對人可隨時了解內容之狀態 2.可避免相對人以任意性行為左右非對話意思表示效力之發生時點[22]。

然而吳從周老師採取否定說，**以相對人實際領取之時間為意思表示到達之時**，其認為 1.依社會通念對到達概念之理解，應該有時間連續以及空間上之占有可能性為前提，**將信件寄存於郵局並且受限於郵局的上班時間始得領取，無論在時間與空間的「支配範圍」上，都難以擴大評價為處於「隨時」知悉內容之可能性** 2.如果寄件人可以證明是因為受領人**有故意拒絕領取郵件或者其他故意妨礙送達之積極行為時**，則應可透過誠信原則之解釋或者**民法第 101 條關於條件成就之規定，擬制其發生送達之效力**[23]。

王澤鑑老師、陳自強老師認為，**收件人受招領通知書之時，不能認為意思表示已經達到，因為該意思表示尚未進入相對人之支配範圍**，是以，**應以收件人得最早可以到達郵局領取之日**，避免收件人透過拒絕領取規避表意人之意思表示達到[24]。

另外，應注意者，現在電子設備逐漸發達，當事人之間透過電子設備進行通訊在所多有，此時如何判斷非對話之意思表示是否達到？

延伸討論：透過電子設備所為非對話意思表示之達到

就電子郵件而言，陳自強老師認為，雖然傳送電子郵件之時即處於隨時可以下載閱讀的狀態，然而並不應該認為此時意思表示已經達到，應區分相對人性質而異：1.若為機關行號，應於營業日開始時達到 2.若為非機關行號之個人，因為使用電腦之習慣有異，仍不應該將電子郵件與一般信箱相比擬，而無達到之效力[25]。

至於使用通訊軟體傳送簡訊等，目前有實務見解認為，除法律另有規定、當事人另有約定，或相對人能證明其客觀上有不能讀取之正當事由外，**應認以該電子文件進入該資訊系統之時，表意人之意思表示已達到相對人而**

[21] 礙於篇幅便不收錄全文，請同學務必自行查詢原文閱讀
[22] 像是相對人一直遲遲不去領郵件，那表意人的意思表示不就完全沒有辦法發生效力了嗎？
[23] 吳從周，民事大法庭裁定選評之二：「掛號郵件製作招領通知單置於信箱」案──評最高法院 109 年度台上大字第 908 號裁定，月旦裁判時報，115 卷 115 期，頁 37、38，2022 年。
[24] 王澤鑑，註 6，頁 440–442；陳自強，註 3，頁 56。
[25] 陳自強，註 3，頁 58。

發生效力，不以相對人實際讀取為必要[26]。

肆、意思表示合致

民法第 153 條

I. 當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立。

II. 當事人對於必要之點，意思一致，而對於非必要之點，未經表示意思者，推定其契約為成立，關於該非必要之點，當事人意思不一致時，法院應依其事件之性質定之。

意思表示內容全部一致	意思表示必要之點[27]一致，非必要之點未表示意見	意思表示必要之點一致，非必要之點不一致
契約成立	契約推定成立	契約不成立

上述條文的思考大致可以簡化為上述的條文，然而應該注意的是，非必要之點意思不一致，契約應該不成立，何來條文所稱非必要之點意思表示不一致而由法院酌定，其原因在於，非必要之點通常當事人在磋商中未置一詞或是仍在討論，然而尚未合意契約即以推定成立，雖然可以反證推翻，然而實務上鮮有案例，此時對於非必要之點的不合意，即需要透過法院酌定[28]。

伍、要約與承諾

一、要約

民法第 154 條

I. 契約之要約人，因要約而受拘束。但要約當時預先聲明不受拘束，或依其情形或事件之性質，可認當事人無受其拘束之意思者，不在此限。

II. 貨物標定賣價陳列者，視為要約。但價目表之寄送，不視為要約。

民法第 155 條

[26] 「按非對話而為意思表示者，其意思表示以通知達到相對人時，發生效力，民法第 95 條第 1 項定有明文。乃採達到主義。所謂達到，係指意思表示已進入相對人之支配範圍，置於相對人隨時可了解其內容之客觀狀態而言。是以表意人將其意思表示以電子文件方式發送至相對人指定之資訊系統者，除法律另有規定、當事人另有約定，或相對人能證明其客觀上有不能讀取之正當事由外，應認以該電子文件進入該資訊系統之時，表意人之意思表示已達到相對人而發生效力，不以相對人實際讀取為必要。」最高法院 112 年度台上字第 1566 號民事判決參照。此判決亦經臺灣新北地方法院 114 年度訴字第 1501 號民事判決引用。

[27] 必要之點在有名契約下比較好判斷，例如買賣契約下就是價金跟買賣之物，但並非僅有法條規定的才有可能成為必要之點，亦可能因為當事人特別注意而成為必要之點，如「所謂必要之點通常固指契約之要素，但對於契約之常素或偶素，當事人之意思如特別注重時，該常素或偶素亦可成為必要之點。」最高法院 99 年度台上字第 60 號民事判決參照。

[28] 王澤鑑，債法原理，增訂新版校正版，頁 210，2024 年。

要約經拒絕者，失其拘束力。

民法第 156 條

對話為要約者，非立時承諾，即失其拘束力。

民法第 157 條

非對話為要約者，依通常情形可期待承諾之達到時期內，相對人不為承諾時，其要約失其拘束力。

民法第 158 條

要約定有承諾期限者，非於其期限內為承諾，失其拘束力。

所謂要約，指要約人有意訂立契約，對外表示確定或可得確定之契約內容，並於相對人承諾時，要約人即受契約拘束之意思表示[29]。此定義的重點在於該要約，必須要可以確定契約之內容，否則無從因承諾而受契約拘束之效力[30]。若表意人並無表示願受契約拘束之意，而僅引誘相對人對自己為要約，此為要約之引誘[31]。

兩者在區分上並不容易，王澤鑑老師提出幾樣參考的的判準：1.表示內容是否詳盡 2.是否注重相對人性質[32]3.要約是否向一人或多數人為之[33]4.當事人間的磋商過程 5.交易慣例[34]，即便透過上述判斷標準，在個案上有時也難以得出絕對的答案，陳自強老師表示要約認定之問題，某種程度上是在進行利益衡量[35]，因此在解題上，僅需詳盡的進行涵攝，結論如何並不重要。以下挑選僅個考試上較有爭議之案型

1. 貨物標定賣價陳列
   此種情況下立法者明訂為要約，並無解釋空間。例如在 Uniqlo 架上的衣服。然而在無法條明文的情況下，德國通說認為，此時為了避免展示之貨品出售可能會造成在無存貨下店家無法達到展示功能，因此在交易習慣上應該解釋為要約之引誘[36]。
2. 價目表寄送
   此種情況下立法者明訂為要約，並無解釋空間，如此亦符合交易習慣[37]。
3. 預售屋廣告

[29] 陳聰富，論契約上之要約，月旦法學雜誌，312 期，頁 71，2021 年。
[30] 條文規定可以參民法第 155 條至 158 條。
[31] 陳自強，註 3，頁 64。
[32] 例如在家教網上有許多人都會刊登廣告，此時通常不會認為構成要約，因為是否為適合的人，都是要面試之後才知道，如此解釋也比較符合交易常態。
[33] 舉例而言，在電線桿上的出售房子的廣告，因為同時對多數人為之（路過的人），如果說每個人都向欲出售的人表示願買，則因為房子僅有一間，故勢必會對其他承諾之人構成債務不履行（主觀給付不能），為了避免履約能力不足，僅能如此解釋。
[34] 王澤鑑，註 28，頁 181。
[35] 陳自強，註 3，頁 64、65。
[36] 陳自強，註 3，頁 68。
[37] 因為價目表寄送會對多數人為之，反而可能使得商人締結過多的契約而承擔違約之風險。

延伸討論：預售屋廣告之性質？

預售屋廣告之性質，難以一概而論，因為當雙方當事人已經透過後續的磋商將預售屋廣告認定為契約之一部，則非要約之引誘[38]。較有爭議之案型：雙方當事人對於廣告之內容並未洽談[39]，而嗣後當事人主張該廣告為契約之一部，此時該廣告是否構成要約進而為契約之一部[40]？而即便不構成要約，是否仍為契約之一部，涉及消保法的規定。

消費者保護法第 22 條

I. 企業經營者應確保廣告內容之真實，其對消費者所負之義務不得低於廣告之內容。

II. 企業經營者之商品或服務廣告內容，於契約成立後，應確實履行。

實務有見解認為，若簽約賣方未就該預售屋之廣告內容進行磋商，尚難認為當然構成要約或契約之一部[41]。此實務見解似乎認

[38] 實務案例如：「查上訴人將廣告平面圖放置於售屋現場供人取閱，固屬要約之引誘，然被上訴人受此要約之引誘後，已進而與上訴人之售屋小姐洽談買賣，售屋小姐並依據該平面圖向被上訴人解說，進而表示買賣房屋之坪數均按該平面圖所示，被上訴人因該平面圖所說明之坪數而決定簽約訂購，參酌證人曾陳素雲所證：上訴人之售屋小姐表示房屋坪數是照廣告平面圖建造，有算出公共設施是四·五坪，伊與被上訴人林宗籐認為划得來始付定金等情，即足認定上開平面圖所示房屋之私有面積，公共面積及房屋之格局等項，確已成為兩造間合致之意思表示，亦即成為買賣契約之內容，而非單純之要約引誘可比。」最高法院 83 年度台上字第 1837 號民事判決參照，相同意旨，最高法院 87 年度台上字第 1190 號判決參照。

[39] 此時按照前述判準，通常認為是要約之引誘，然而即便認為是要約之引誘，不當然不構成契約之一部。

[40]消費者保護法第 17 條第 1 項授權內政部可以擬訂定型化契約應記載或不應記載事項，若違反則依照同條第 4 項無效或依照第 5 項構成契約之內容，而根據行政院公布之預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項之應記載事項之二、：賣方應確保廣告內容之真實，本預售屋之廣告宣傳品及其所記載之建材設備表、 房屋及停車位平面圖與位置示意圖，為契約之一部分。因此預售屋廣告的定型化契約受到非常嚴格的管制。

[41] 「按 104 年 6 月 17 日修正前消保法第 22 條規定：「企業經營者應確保廣告內容之真實，其對於消費者所負之義務不得低於廣告內容」，並未明定「廣告為要約」或「廣告為契約內容之一部」。又廣告具有多樣性及複雜性，是否屬契約之一部，仍應參酌當事人之意思，包括廣告表示內容是否具體詳盡、當事人之磋商過程、交易慣例等綜合判斷。如消費者信賴廣告內容，依企業經營者提供之廣告訊息與之洽談而簽訂契約，於契約中雖未就廣告內容再為約定，企業經營者所應負之契約責任，仍及於該廣告內容，該廣告固應視為契約之一部。惟簽訂契約時倘企業經營者並未再據原屬「要約引誘」之廣告為訂約之說明、洽談，使之成為具體之「要約」，縱其廣告之內容不實，應受消保法或公平交易法之規範，**仍難逕謂該廣告為要約或已當然成為契約之一部**。本件上訴人於事實審一再抗辯伊委託之廣告文宣，僅強調建築外觀之清新、美觀等抽象性描繪，買方與伊之銷售人員並未就建築外觀特別提出要求或說明，建築外觀非兩造契約之一部分等語（見原審卷第 56、58 頁）。觀諸上訴人之廣告文宣記載：「反應自然的一抹留白…耀眼的白色外觀賦予清新的建築表情」；「對於紐約白派建築大師理查邁爾而言，白是包容一切的顏色…」；「白色柱列有如高聳入雲的大樹，也仿佛白色的羽翼向天空昂然伸展」等文字（見一審卷第 44、46、151、154 頁）；參以證人即系爭建案銷售人員吳岱璉證稱：伊並未向消費者說明將來建物是白色的，伊接手的客人亦未強調喜歡白色外觀等語；證人即看屋者高慧齡證稱：當時接待人員放影片及帶看模型、樣品屋，伊看到模型是白色的，伊忘記是否有介紹係白色外

為，即便有消費者保護法第 22 條之適用，不一定會構成契約之內容。

陳忠五老師認為，上開判決似乎將預售屋廣告是否構成契約之一部，繫諸於該廣告是否為要約或要約之引誘，忽視了消費者保護法第 22 條之規定，而是否構成消費者保護法第 22 條而使得該廣告構成契約之內容，則繫諸於消費者是否有客觀和主觀上之信賴，前者，係該廣告之內容客觀上需要具體到可以履行[42]；後者，需消費者在善盡交易上合理之注意義務後仍信賴該廣告，方有本條之適用[43]，若肯定之，則該廣告構成契約之內容[44]。

綜上所述，上開問題可以簡化思考流程如下：

Step1.判斷該廣告係要約[45]或要約之引誘→要約，構成契約

↓

Step2.若為要約之引誘，是否構成消保法第 22 條→是，構成契約

↓

Step3.若不構成消保法第 22 條，是否有其他規定之適用（消保法第 14 條或審閱期間之限制）

4. 網路商業廣告

網路上之商業廣告，因為商人之存貨必定有限，為了避免商人因為與過多的相對人訂約而產生債務不履行之問題，因此比較法、

觀建物，但因考量預算而購買他處等語；證人即購屋者莊珍惠證稱：銷售人員介紹是白色外觀，伊於看屋未下訂前，並未向銷售人員表示在意外觀顏色等語（見一審卷第 302 頁背面、第 303 頁，第 304 頁背面、第 305 頁，第 280 頁）；復酌系爭契約第 10 條第 1 項、第 11 條第 3 項之約定（見一審卷第 9 頁），似非全然無稽。上訴人之廣告文宣，就建築外觀顏色，是否已具體明確表示係「純白」色，而可為契約之內容？倘是，被上訴人是否與上訴人就該純白色外觀之廣告訊息已為洽談、說明，兩造使之成為要約而簽訂契約？又系爭契約明訂上訴人有建築外觀（包括顏色）修正權，兩造有無將該廣告內容排除於契約之外？均非無疑，自待探求釐清。乃原審未察，就上訴人上開抗辯，未調查釐清，說明其心證之所得由，即逕以上訴人之廣告文宣已事實上描述純白色外觀建物，已足使消費者產生信賴，即為契約內容之一部，遽為不利上訴人之論斷，非無違誤。」最高法院 108 年度台上字第 1201 號民事判決參照。

[42] 例如預售屋廣告不曉得為甚麼都會有一些很瞎趴的形容詞像是君臨天下阿人文薈萃阿，最基本的也會主張周邊生活機能方便，然而上述都難以被評價為具體而無法被履行。

[43] 如果說消費者本來就知道這個廣告是假的你還去簽約，就難以說該消費者有保護的正當性，例如雙方就廣告已經有例外的約定排除廣告內容。然而陳忠五老師也認為，此時為了避免企業經營者透過締約優勢排除廣告之效力，應該嚴格解釋該排除之約定是否構成個別磋商條款，或是違反消保法第 14 條、審閱期間等限制。

[44] 陳忠五，建物外觀顏色與預售屋廣告的契約效力──最高法院 108 年度台上字第 1201 號判決評釋，月旦法學雜誌，309 期，頁 40–55，2021 年；陳自強，註 3，頁 65–68。

[45] 此時可能因為後續雙方當事人將廣告納入磋商內容進而構成要約

通說成認網路商業廣告為要約之引誘，相對人之訂購方為要約[46]。

然而，在相對人訂購產品而為要約，而商人架設網站自動回信確認訂單，此時是否構成承諾，陳聰富老師認為，德國與日本之實務，均認為其僅為回覆訂單到達之意思通知，並非承諾，然若商人明確表示同意或已經對信用卡進行扣款者，則構成承諾[47]。

5. 要約之失效

(1) 要約經拒絕

按民法第 155 條，要約經拒絕者，失其拘束力。相對人拒絕要約後即便再次為承諾，契約亦不成立。

(2) 對話之要約，非立即承諾

按民法第 156 條，對話為要約者，非立時承諾，即失其拘束力。

(3) 非對話之要約，經相當期限不為承諾

按民法第 157 條，非對話為要約者，依通常情形可期待承諾之達到時期內，相對人不為承諾時，其要約失其拘束力。

(4) 要約定有承諾期限者，非於其期限內為承諾

按民法第 158 條，要約定有承諾期限者，非於其期限內為承諾，失其拘束力。

二、承諾

民法第 159 條

I. 承諾之通知，按其傳達方法，通常在相當時期內可達到而遲到，其情形為要約人可得而知者，應向相對人即發遲到之通知。

II. 要約人怠於為前項通知者，其承諾視為未遲到。

民法第 160 條

I. 遲到之承諾，除前條情形外，視為新要約。

II. 將要約擴張、限制或為其他變更而承諾者，視為拒絕原要約而為新要約。

民法第 161 條

I. 依習慣或依其事件之性質，承諾無須通知者，在相當時期內，有

[46] 陳聰富，註 29，頁 75、76。
[47] 陳聰富，註 29，頁 76。

可認為承諾之事實時，其契約為成立。

II. 前項規定，於要約人要約當時預先聲明承諾無須通知者準用之。

民法第 162 條

I. 撤回要約之通知，其到達在要約到達之後，而按其傳達方法，通常在相當時期內應先時或同時到達，其情形為相對人可得而知者，相對人應向要約人即發遲到之通知。

II. 相對人怠於為前項通知者，其要約撤回之通知，視為未遲到。

民法第 163 條

前條之規定，於承諾之撤回準用之。

所謂承諾，是以與要約人訂立契約為目的，所為的意思表示[48]。為承諾之前提為要約仍有效，而在要約到達相對人之前，表意人均可依照民法第 95 條第 1 項但書、第 162 條撤回之，而承諾之撤回依照民法第 163 條準用前條[49]，流程簡化如下：

<table>
<tr><td>撤回先於要約或同時到達</td><td colspan="4">要約不發生效力</td></tr>
<tr><td rowspan="3">撤回後於要約到達後</td><td rowspan="2">按其傳達方法，通常撤回應先於要約或同時到達</td><td rowspan="2">相對人應向要約人即發遲到之通知</td><td>未為通知者，視為未遲到</td><td>撤回仍生效力，要約不生效</td></tr>
<tr><td>為通知者，仍為遲到</td><td>撤回不生效力，要約仍有效</td></tr>
<tr><td>按其傳達方法，通常撤回後於要約到達</td><td colspan="3">不生撤回之效力，即要約仍有效</td></tr>
</table>

而承諾生效之方式，有以下幾種：

1. 承諾之通知

   即將承諾之意思表示通知他人。

2. 意思實現

   按民法第 161 條第 1 項，依習慣或依其事件之性質，承諾無須通知者，在相當時期內，有可認為承諾之事實時，其契約為成立。此為意思實現之明文規定，然而，可認為承諾之事實究竟為何

[48] 陳聰富，註 29，頁 35。

[49] 撤回與撤銷的差別在於：前者在意思表示尚未發生效力之前阻其效力發生；後者在意思表示生效後使其溯及失其效力。

意，學說上有不同看法，舉例說明：

> 案例：甲為了推銷 A 書，因此未經同意直接將帳單加上 A 書寄送至乙之住所，乙未發現帳單存在，以為該書為其妻所贈，遂加以閱讀並加以眉批。試問：甲、乙就 A 書之買賣契約是否成立？

有實務見解認為，所謂之意思實現，乃依有可認為承諾之事實，推斷有此效果（承諾）意思。意思實現以客觀上有可認為承諾之事實存在為要件，有此事實，契約即為成立。而有無此事實，應依具體情事決定之[50]。換言之，對於為意思實現之人並不要求其主觀上有承諾之意思，契約即可成立且無瑕疵[51]，在本例之中甲、乙契約成立，且乙無救濟之法。

然而學說上多認為，除了客觀上要有可認為承諾之事實，主觀上仍須有承諾之意思[52]，然而應該注意，其是否有承諾之意思，亦應從客觀的角度進行評價。在本例中乙欠缺承諾之意思，可透過錯誤之規定救濟之[53]。

3. 沉默？

單純的沉默，是否可以認為有承諾之效力？原則上沉默並不具有任何效力，避免要約人任意寄送貨物並表示相對人若保留貨物契約即成立的情況[54]，舉例而言：

> 案例：甲為了推銷 A 書，將 A 書寄送至乙家，並附上帳單，表示若不願意購買 A 書，應該將其於七日內退還，否則視為購買，乙置之不理，兩個月後，乙之子丙在 A 書上塗鴉。

在本例中乙沉默並無任何效力，因此甲乙之間的契約並不成立，且甲之表示對乙亦不生任何拘束力，至於 A 書被丙毀損之問題，按消費者保護法第 20 條第 2 項，前項物品之寄送人，經消費者定相當期限通知取回而逾期未取回或無法通知者，視為拋棄其寄投之商品。雖未經通知，但在寄送後逾一個月未經消費者表示承諾，而仍不取回其商品者，亦同。本例甲已經非 A 書之所有人，自無所有權被侵害的問題[55]。

---

[50] 最高法院 95 年度台上字第 969 號民事判決參照。

[51] 因為本例中乙實際上並無表示意思和效果意思，如果實務見解認為意思表示的主觀要素並非要件，那麼乙即便有意思表示有所瑕疵亦不影響，本件契約成立並無任何瑕疵。

[52] 應注意的是，學說認為意思實現亦免除了通知的義務，意即該意思實現之行為無須通知要約人，契約亦可成立。

[53] 陳聰富，註 29，頁 36；陳自強，註 3，頁 91、92。

[54] 陳自強，註 3，頁 93、94；陳聰富，註 29，頁 37。

[55] 陳自強，註 3，頁 93、94。

然而，在雙方當事人有特別約定或是有交易慣例認為沉默構成承諾時，沉默即會發生承諾之效力[56]，例如：

> 案例：甲常常跟乙進新衣服，若有最新服飾，乙會發出款式向甲詢問甲是否願意購買，雙方約定若甲三天內未為回覆，則視為購買。

此時按照雙方之約定，契約成立。

4. 視為新要約之情況

(1) 變更要約

承諾必須和要約的內容完全相符，如此契約方得成立，此在英美法下稱為「鏡像原則」（mirror image rule）[57]，我國實務亦採此說[58]。而只要不符合原先要約之內容，則依照民法第 160 條第 2 項視為新要約，則仍需相對人為承諾，契約方得成立，舉例而言：

> 案例：甲詢問乙是否欲購買其所有之 A 屋，乙則表示若甲重新進行內部裝潢，則願意購買 A 屋，甲欣然允之。

(2) 承諾遲到

按民法第 160 條第 1 項，遲到之承諾，除前條情形外，視為新要約。而承諾是否遲到，取決於民法第 159 條之規定，按照前述流程判斷即可。而承諾遲到時，視為新要約，相對人可對表意人為承諾使契約成立，學說上認為此種制度設計可以讓契約更容易成立[59]。

陸、虛偽意思表示

一、單獨虛偽意思表示

> 民法第 86 條
> 表意人無欲為其意思表示所拘束之意，而為意思表示者，其意思表示，不因之無效。但其情形為相對人所明知者，不在此限。

舉例而言：

> 案例：甲身無分文，而到乙之餐廳用餐，向乙表達點餐之意，然而甲之內心則希望契約不要成立而可以白吃白喝。

---

[56] 陳自強，註 3，頁 95；陳聰富，註 29，頁 38。
[57] 陳聰富，註 29，頁 40。
[58] 「契約如因要約與承諾而成立者，其承諾之內容必須與要約之內容完全一致（客觀上一致），契約始能成立；若當事人將要約擴張、限制或為其他變更而承諾者，應視為拒絕原要約而為新要約（同法第一百六十條第二項），契約尚不能成立。」最高法院 103 年度台上字第 1844 號民事判決參照。
[59] 陳聰富，註 29，頁 46。

本件甲之意思表示實際上並無任何瑕疵，客觀上甲有點餐的表示行為，主觀上亦有行為意思，甲也明知該行為會有法律意義，且其效果為成立買賣契約，故亦有表示意思和效果意思，充其量僅是甲內心不願意受到契約之拘束，此時按照民法第 86 條本文，意思表示仍為有效，乙承諾後契約成立[60]。至於但書則是在相對人明知其無受拘束之意，意思表示仍然生效。

二、通謀虛偽意思表示

民法第 87 條

I. 表意人與相對人通謀而為虛偽意思表示者，其意思表示無效。但不得以其無效對抗善意第三人。

II. 虛偽意思表示，隱藏他項法律行為者，適用關於該項法律行為之規定。

本條即學說上所謂通謀虛偽意思表示，其指表意人與相對人通謀而虛偽的意思表示[61]，其效果依照民法第 87 條第 1 項本文，其意思表示無效。舉例而言：

案例：甲、乙之間有 A 屋之買賣契約，然而乙害怕被甲強制執行 A 屋，遂和丙假裝為 A 屋之買賣契約，並辦理所有權移轉登記完畢且交屋給丙。試問：甲應該如何主張權利？

本件中乙丙之間有兩個法律行為，分別為買賣契約和物權契約（A 屋所有權移轉），而乙丙並無實際上買賣並履行契約之意，兩者均因民法第 87 條第 1 項本文而無效，乙仍為實際上 A 屋的所有人，然而登記名義人為甲，按照立法理由[62]，在乙丙之間的所有權移轉登記被塗銷之前，丙仍為 A 屋之所有人，甲不得請求乙移轉 A 屋所有權[63]。

---

60 陳自強，註 3，頁 208、209。

61 王澤鑑，註 6，頁 455。

62 本條立法理由：「一、本條新增。 二、「登記」與「占有」同為物權公示方法之一，民法就占有既於第九百四十三條設有權利推定效力之規定，「登記」自亦應有此種效力，爰仿德國民法第八百九十一條、瑞士民法第九百三十七條第一項規定，增訂第一項，以期周延。又此項登記之推定力，乃為登記名義人除不得援以對抗其直接前手之真正權利人外，得對其他任何人主張之。為貫徹登記之效力，此項推定力，應依法定程序塗銷登記，始得推翻。至於土地法第四十三條雖規定依該法所為之登記有絕對效力；惟實務上向認在第三者信賴登記而取得土地權利之前，真正權利人仍得對登記名義人主張登記原因之無效或撤銷（最高法院四十年台上字第一八九二號判例參照），是該條文所稱絕對效力，其範圍既僅止於保護信賴登記之善意第三人，其效果自與新增之本條文無異。惟為免文義兩歧，於修正土地法時，應將第四十三條配合本條修正。 三、不動產物權之登記所表彰之物權如與實際狀態不一致，例如無所有權登記為有所有權，或土地有地上權負擔而未登記該地上權等不實情形。為確保善意第三人之權益，以維護交易安全，爰依上開解釋、判例及參照德國民法第八百九十二條、瑞士民法第九百七十三條規定，增訂第二項。」

63 此實務見解之不當，詳細批評可參張譯文，土地登記的推定力——兼評最高法院 108 年度台上字第 23 號民事判決，台灣法律人，10 期，頁 155–163，2022 年。

是以，本件甲應該先依民法第 242 條代位乙向丙主張民法第 767 條第 1 項前段、中段塗銷 A 屋之所有權移轉登記並返還 A 屋，再請求乙移轉並交付 A 屋。

至於甲得否依照侵權行為之規定，一同起訴乙、丙塗銷 A 屋之所有權移轉登記，過去實務認為，因為債務人乙本來就有自由移轉其所有權之權利，故不構成侵權行為[64]。然而實務亦有認為民法第 242 條和侵權行為可以二擇一行使[65]。應該說明的是，前揭決議之否定論述對於民法第 184 條第 1 項前段實屬正確，然而，民法第 184 條第 1 項後段之保護客體，並不以侵害權利為必要，損害他人利益亦屬之，本件乙丙透過通謀虛偽移轉 A 屋所有權之方式，造成甲之債權無法獲得滿足，可認為利益有受到侵害，而構成民法第 184 條第 1 項後段之責任[66]。

而所謂通謀虛偽意思表示依照第 1 項但書不得對抗第三人，乃是為了保護交易安全，因為第三人未必知悉該通謀虛偽意思表示乃是虛偽，舉例而言：

> 案例：甲債台高築且名下僅剩 A 屋一棟，甲為了避免 A 屋被債權人強制執行，遂以假買賣之名義移轉 A 屋所有權給好友乙，殊不知好友乙卻將 A 屋所有權依照買賣名義移轉給善意之第三人丙。試問：丙是否取得 A 屋所有權；若甲所剩之財產乃是對丁之一筆債權，結論是否有所不同？

在物的所有權移轉之下，因為物權編章已經設有善意取得之特別規定，是以，應優先適用該規範（民法第 759 條之 1 第 2 項）；然而在債權移轉之情況下，並無上開規定適用，故本條規定仍具有實益[67]。但第三人向虛偽受讓物之人締結租賃契約，是否有本條適用？學說上有不同見解，舉例如下：

> 案例：甲債台高築且名下僅剩 A 屋一棟，甲為了避免 A 屋被債權人強制執行，遂以假買賣之名義移轉 A 屋給好友乙，乙復將 A 屋出租於善

---

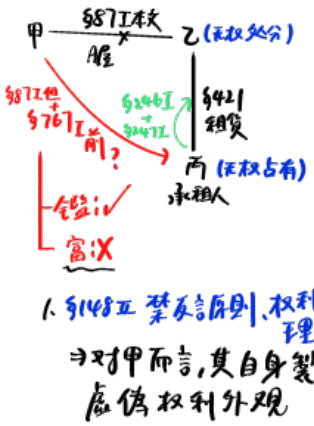
64 「按債務人與第三人通謀移轉其財產，其目的雖在使債權無法實現，而應負債務不履行之責任，但將自己之財產予以處分，原可自由為之，究難謂係故意不法侵害債權人之權利，故與侵害債權之該第三人不能構成共同侵權行為 (參看史尚寬先生著債法總論) ，債權人如本於侵權行為訴請塗銷登記時，參照本院六十七年度第五次民事庭庭推總會決議，僅得向該第三人為之，債務人既非共同侵權行為人，自不得對其一併為此請求。」參照最高法院 69 年度第 7 次民事庭會議決議（三）。

65 「債務人欲免其財產被強制執行，與第三人通謀而為虛偽意思表示，將其所有不動產為第三人設定抵押權者，債權人可依侵權行為之法則，請求第三人塗銷登記，亦可行使代位權，請求塗銷登記。二者之訴訟標的並不相同。」最高法院 73 年度台抗字第 472 號民事裁定參照。

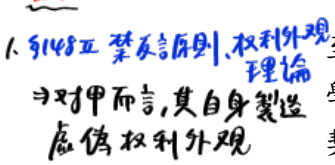
66 王澤鑑，註 6，頁 459、460。

67 王澤鑑，註 6，頁 457、458。

意之第三人丙。試問：甲得否依民法第 767 條第 1 項前段向丙請求返還 A 屋之占有？



王澤鑑老師認為，所謂第三人必以其財產上之權利義務關係因通謀虛偽意思表示無效而受有影響，本件即便甲乙之所有權移轉行為無效，乙丙仍可簽訂租賃契約，故非此處所稱之第三人[68]；陳聰富老師認為，即便是在上述出賣給善意第三人之情況下，買賣契約效力亦不受影響，何以在租賃契約做出不同判斷，是以，不論是因買賣契約或是租賃契約而受讓者，均受本條之保護[69]。



至於第三人利益契約下之受益人，是否屬於本條所稱之第三人？多數學說認為並不包含之，因為按照民法第 270 條之規定，債務人可以以契約一切抗辯對抗受益人，當然包含本條第 1 項本文無效之規定[70]。

柒、錯誤

民法第 88 條

I. 意思表示之內容有錯誤，或表意人若知其事情即不為意思表示者，表意人得將其意思表示撤銷之。但以其錯誤或不知事情，非由表意人自己之過失者為限。

II. 當事人之資格或物之性質，若交易上認為重要者，其錯誤，視為意思表示內容之錯誤。

民法第 89 條

意思表示，因傳達人或傳達機關傳達不實者，得比照前條之規定撤銷之。

民法第 90 條

前二條之撤銷權，自意思表示後，經過一年而消滅。

民法第 91 條

依第八十八條及第八十九條之規定撤銷意思表示時，表意人對於信其意思表示為有效而受損害之相對人或第三人，應負賠償責任。但其撤銷之原因，受害人明知或可得而知者，不在此限。

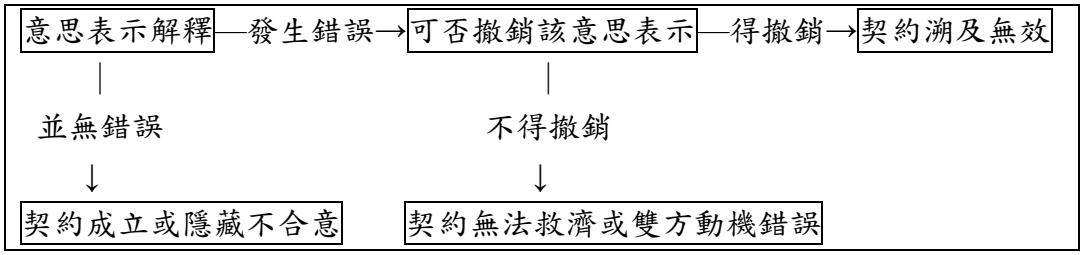
所謂錯誤，可以區分成與意思表達階段之錯誤和意思形成階段之錯誤，前者屬於民法第 88 條第 1 項所欲處理的；後者屬於第 2 項所欲處理的。根據條文整理如下[71]：

	類型	撤銷之依據	內容
意思表達階	內容錯誤[72]	民法第 88 條	意思表示之內容有錯誤

[68] 王澤鑑，註 6，頁 457。
[69] 陳聰富，註 2，頁 339、340。
[70] 陳聰富，註 2，頁 340；王澤鑑，註 6，頁 457、458。
[71] 整理自陳自強，註 3，頁 225–228。
[72] 誤認語言意義，例如誤會 A 地為 B 地

段之錯誤		第 1 項前段	
	表示行為錯誤[73]	民法第 88 條第 1 項後段	表意人若知其事情即不為意思表示
	傳遞錯誤	民法第 89 條	因傳達人或傳達機關傳達不實
意思形成階段之錯誤[74]	當事人性質或物之性質錯誤	民法第 88 條第 2 項	當事人之資格或物之性質，若交易上認為重要
	動機錯誤	不得撤銷	當事人之資格或物之性質，若交易上不認為重要

在判斷是否錯誤之前，應先進行意思表示解釋，此即為意思表示解釋優先[75]。因此判斷流程如下。



契約成立之前提，必然是意思表示合致，隱藏不合意，則契約亦不成立，自無撤銷之必要，舉例而言：

> 案例：外省二代之甲向台灣農夫乙表示欲購買十公斤之土豆，然而土豆在中國之意係指馬鈴薯，在閩南語則有指花生之意。試問：甲、乙之契約是否成立？

在此例下，甲乙內心與外在表示並無不一致之情況，僅是因為語言之多義性，導致雙方意思表示不一致而不知，此時契約不成立[76]。

誤載不害真意(隱藏合意)

應和上述相區別者，乃是用語錯誤無害真意之情況，舉例而言：

> 案例：甲向食品行老闆丙表示欲購買「腐竹」，甲乙均認為「腐竹」為豆皮之別稱，然而「腐竹」實則為另一種食材。試問：甲、乙對於豆皮買賣契約是否成立？

所謂用語錯誤無害真意，乃是雙方當事人之真正合意，優先於意思表示之文句[77]。本件既然甲乙真意乃是買賣豆皮而非腐竹，就此雙方意思表示合

[73] 並無誤認語言意義（即主觀上並無誤認），但是表達出來時發生錯誤，例如要買 A 地卻寫錯成 B 地
[74] 陳聰富，註 2，頁 354、355。
[75] 陳聰富，註 2，頁 352；陳自強，註 3，頁 232–239。
[76] 陳聰富，註 2，頁 353、354。
[77] 陳聰富，註 2，頁 352、353。

致，並無錯誤或不合意之問題。

一、內容錯誤

所謂內容錯誤，係指表意人表示其所欲為之表示，但誤認其表示之客觀意義，而通常為當事人或物之同一性之誤認[78]。此為民法第 88 條第 1 項前段所規定。雖然本項並無要求交易上重要，但學說上認為仍有此要求[79]。本條所欲規範之狀況，舉例而言：

> 案例：甲欲購買乙地號為 XXXXXXXX 之 A 地，然而甲卻以為 A 地之地號為 OOOOOOOO，實際上乙確實有地號為 OOOOOOOO 之 B 地，且乙不知悉甲誤認地號之情事而欣然允之。

二、表示行為錯誤

所謂表示行為錯誤，即表意人誤其表示為其所欲表示者，通常情況下乃是誤言、誤寫[80]。此為民法第 88 條第 1 項後段所欲規範者。其與內容錯誤之最大差別在於，錯誤發生之原因並相同，內容錯誤是因為表意人主觀上對其所用之語言意義有所誤認，表示行為錯誤則是表意人主觀上對其所用之語言意義並無誤認，而僅是表現於外時發生錯誤。另外學說上亦認為雖然本項並無要求交易上重要，但學說上認為仍有此要求[81]。舉例而言：

> 案例：甲欲向乙購買其所有地號為 123456787 之 A 地，然而在寄信給乙的時候地號不小心寫成 123456789，恰好乙亦有地號為 123456789 之 B 地而欣然允之。

此案例中甲對於 A 地之地號並無誤認，僅是在謄寫的時候誤寫，為表示行為錯誤。

三、傳遞錯誤

按意思表示，因傳達人或傳達機關傳達不實者，得撤銷之。舉例而言：

> 案例：甲請弟弟乙傳話告知丙其欲購買丙所有之 A 地，然而乙誤說為 B 地。

此種情況下甲仍可撤銷其購買 B 地之要約。但如此似乎對乙有所不周，尤其是在乙故意傳達不實的情況下，如：

> 案例：甲請弟弟乙傳話告知丙其欲購買丙所有之 A 地，然而乙故意告知丙甲欲購買 B 地。

---

78 王澤鑑，註 6，頁 475。
79 陳自強，註 3，頁 245。
80 王澤鑑，註 6，頁 475、476。
81 陳自強，註 3，頁 245。

此種情況下甲仍可撤銷，然而學說上有認為丙可類推適用民法第 110 條向乙請求損害賠償[82]。

立法論上，表意人似乎比相對人更有能力控管傳達人是否傳達不實，傳達不實的風險是否應依我國民法第 89 條由相對人承擔，值得深思[83]。

四、當事人資格或物之性質錯誤

當事人作出意思表示的過程，時常受到許多不同因素的影響，例如自己的需求、標的物的狀況、相對人的狀況、市場的狀況，此種使得意思表示形成的因素，屬於所謂的動機錯誤[84]。而意思表示形成之有關之事實認知是否正確，應由表意人自己承擔，故動機錯誤原則上無保護的必要，其理由並非因為動機相對人難以得知[85]。然而，我國民法第 88 條第 2 項例外將當事人資格以及物之性質之動機錯誤納入可以撤銷的範疇，其撤銷之要件如下：

1. 當事人資格或物之性質錯誤

當事人資格，如職業、健康狀態、刑罰前科、聲望、支付能力等，物之性質則指足以影響物的使用以及價值的事實或法律關係，應注意者物之市場價值並不屬之，因為市場價值並非存在於物上[86]。

2. 交易上重要

如何判斷交易上重要，實務認為應採主客觀標準，主觀乃是表意人若無此錯誤即不為該意思表示，客觀則為一般客觀之判斷具有重要性[87]。然而亦有學說主張應該交易上重要性應判斷該動機是

---

82 王澤鑑，民法總則增補新版，2024 年，頁 482。
83 王澤鑑，民法總則增補新版，2024 年，頁 482。
84 陳自強，民法總則法律行為五版，2023 年，頁 225-227。
85 陳自強，民法總則法律行為五版，2023 年，頁 243。相反見解認為動機錯誤不受保護的原因乃是因為相對人難以得知者，參王澤鑑，民法總則增補新版，2024 年，頁 472、473。
86 王澤鑑，民法總則增補新版，2024 年，頁 477、478。
87 「按民法第八十八條第一項所稱之錯誤，固僅存於「意思表示內容」之錯誤（誤認其表示之內容）及「意思表示行為」之錯誤（誤用其表示之方法），然存於「當事人之資格或物之性質」之錯誤（在本質概念上，祇有動機之錯誤，並無意思與表示之不一致），若從社會經濟而言，在交易上認為重要者，各該錯誤即等同誤認人或物之同一性，同條第二項乃就此設有「其錯誤，視為意思表示內容之錯誤」之規定，以資兼顧。是以當事人之資格或物之性質，在交易上認為重要而有錯誤，倘當事人主觀上知其情事，即不為意思表示，而依一般客觀上之判斷，亦係如此者，當視同其表示內容之錯誤，蓋其資格或性質，既在交易上認為重要，而其錯誤在主、客觀上俱為嚴重，則通常可認其資格或性質為法律行為之基礎，並應為相對人所明知或可得而知。於此情形，該錯誤之表意人自非不得依該條第二項規定將其意思表示撤銷之，始不失該條項規範之真諦。」最高法院 98 年度台上字第 1469 號民事判決參照，學說上見解可參陳自強，民法總則法律行為五版，2023 年，頁 246、247。

否有成為約定之內容，而由雙方當事人作為契約之基礎[88]。

應注意者，本要件應該一併適用於民法第 88 條第 1 項之錯誤撤銷之限制[89]。

五、錯誤非由表意人自己之過失而致

此要件雖然僅規定於民法第 88 條第 1 項，然而民法第 88 條第 2 項亦應有此要件，因為當事人資格或物之性質之錯誤，視同視為意思表示內容之錯誤，是以，仍以民法第 88 條第 1 項撤銷須非由表意人自己過失所致方可為之。

而條文所稱之過失，實務認為屬於具體輕過失[90]，學說上有認為乃抽象輕過失而維護交易安全[91]。然而陳自強老師認為，上開見解難以提供實質判準，其認為應該進行當事人之利益衡量，若錯誤係因相對人引起，或該錯誤對於相對人來說極其明顯，則非表意人之過失[92]。

六、除斥期間

按民法第 90 條，意思表示錯誤之撤銷權，自意思表示後，經過一年而消滅。該除斥期間極短，若個案上無法主張錯誤撤銷，或可思考有無民法第 92 條之適用。

七、損害賠償

按民法第 91 條，撤銷意思表示時，表意人對於信其意思表示為有效而受損害之相對人或第三人，應負賠償責任。但其撤銷之原因，受害人明知或可得而知者，不在此限。受害人明知或可得而知者不得撤銷，乃是因為其既然明知則無保護必要，而其損害賠償責任，通說認為乃是信賴利益[93]。

八、雙方動機錯誤？

當雙方以錯誤之共同認知作為締約之基礎時，即所謂「法律行為基礎不存在」，應該如何救濟[94]？舉例說明：

從同法別 富法雄律 字227-2

[88] 陳聰富，意思表示單方錯誤與雙方錯誤──最高法院 110 年度台上字第 371 號民事判決評釋，月旦法學雜誌，325 卷 325 期，頁 97、98，2022 年；陳自強，註 3，頁 244；王澤鑑，註 6，頁 479、480。
[89] 王澤鑑，註 6，頁 486、487；陳自強，註 3，頁 245。
[90] 最高法院 62 年度台上字第 140 號民事判決。
[91] 王澤鑑，註 6，頁 485、486。
[92] 陳自強，註 3，頁 247、248。
[93] 王澤鑑，註 6，頁 488、489；陳自強，註 3，頁 251、252。
[94] 在德國法上，因為其有明文規定處理此種交易基礎不存在的問題，德國民法第 313 條第 2、3

> 舉例：定作人乙委託承攬人甲挖掘隧道，雙方在締約前進行地質探勘以決定工期，該報告指出隧道路徑的地質較為鬆軟，因此甲、乙雙方便以此報告為基礎締結承攬契約，殊不知動工到一半的時候，發現地質並非如同報告顯示一樣鬆軟，而是具有堅硬之岩層，因此甲向乙請求延展工期，乙拒絕之。

在此例下，甲可以適用民法第 88 條第 2 項撤銷該承攬契約，然而實際上可能會造成工程進行到一半回復原狀的困難[95]，甲更可能會負擔民法第 91 條之損害賠償責任，因此錯誤之法則在此例之下難以妥適的處理此問題。

而陳聰富老師認為，此時應該要依誠信原則或類推適用民法第 227-2 條情事變更原則來調整契約，若雙方不願意維持契約，則可解消契約[96]；而吳從周老師則認為，我國立法者認為民法第 227-2 條之情事變更並不適用於主觀上締約基礎不存在[97]，因此難以認為存在法律漏洞而無法進行類推適用，因此應該透過民法第 1 條將德國民法第 313 條第 2 項規定引為法理，加以適用[98]。

貳、詐欺或強暴脅迫

> 民法第 92 條
>
> I. 因被詐欺或被脅迫而為意思表示者，表意人得撤銷其意思表示。但詐欺係由第三人所為者，以相對人明知其事實或可得而知者為限，始得撤銷之。
>
> II. 被詐欺而為之意思表示，其撤銷不得以之對抗善意第三人。
>
> 民法第 93 條
>
> 前條之撤銷，應於發見詐欺或脅迫終止後，一年內為之。但自意思表示後，經過十年，不得撤銷。

項：「（第 2 項）作為契約基礎之重大觀念被證明是錯誤時，視為情事之變更。（第 3 項）倘調整契約是不可能，或對於契約之一方是無法期待時，受損之一方得主張解除契約。在繼續性契約則以終止權代替解除權。」即為明文，雙方可以調整或是解除或終止契約，然而我國法之情事變更原則僅適用於訂約後之情事變更，觀我國民法第 227-2 條第 1 項：「契約成立後，情事變更，非當時所得預料，而依其原有效果顯失公平者，當事人得聲請法院增、減其給付或變更其他原有之效果。」因此上開問題在我國下遂生爭議。

[95] 相較於德國法下針對繼續性契約可以「終止」契約，我國法下的撤銷按照民法第 114 條乃是溯及失效，因此已經完成之部分工作應該如何處理？該處理方式是否符合雙方利益？仍有許多問題。

[96] 陳聰富，註 88，頁 101–105；王澤鑑，註 6，頁 474、475。

[97] 參民法第 227-2 條之立法理由節錄：「……又情事變更， 純屬客觀事實，當無因可歸責於當事人之事由所引起之事例，故民事訴訟法第三百九十七條規定「因不可歸責於當事人之事由致」等文字無贅列之必要，併予敘明。……」

[98] 吳從周，從工程承攬契約的兩個實務案型再思考情事變更原則之適用要件－以【物價漲跌型】及【工期展延型】之相關判決為中心，政大法學評論，153 期，頁 68–71，2018 年。

表意人被詐欺或脅迫時，處於意思表示不自由之狀態，然而其意思表示仍為有效，僅是其有瑕疵而如何救濟之問題，其與完全無行為意思而不成立並不相同。而條文區分被詐欺以及脅迫，以下分述：

<table>
<tr><th rowspan="5">民法第 92 條</th><th>類型</th><th>行為樣態</th><th>效果</th><th>得否對抗第三人</th><th>除斥期間</th></tr>
<tr><td rowspan="2">詐欺</td><td>作為</td><td rowspan="4">得撤銷之</td><td rowspan="2">不得</td><td rowspan="4">主觀：一年
客觀：十年</td></tr>
<tr><td>不作為</td></tr>
<tr><td rowspan="2">脅迫</td><td>手段不法</td><td rowspan="2">得</td></tr>
<tr><td>手段合法</td></tr>
</table>

一、詐欺

民事法上所謂詐欺云者，係謂欲相對人陷於錯誤，故意示以不實之事，令其因錯誤而為意思之表示[99]。是以，若並非客觀可驗證真偽之事，則不構成詐欺，例如：

> 案例：貴婦甲到服飾店血拚，並選取蒂芬妮藍洋裝一件，詢問店員乙是否好看，乙心裡想甲穿起來難看得要命，但為了拚業績，所以仍稱讚十分適合甲，甲遂購買之，回家穿給閨密丙，丙告訴甲難看得要命，甲傷心至極，遂至乙店要求退貨。

本例中甲穿起來是否好看，並非客觀可驗真偽之事，不構成詐欺。

另外，詐欺以詐欺人有詐欺故意為必要，且相對人必須要為對自己不利之意思表示方該當本條之要件[100]。

而詐欺，又可因為詐欺人積極的表達不實資訊或是消極的隱匿資訊而區分為作為或不作為詐欺：

1. 作為詐欺（虛偽陳述）

   乃是積極的傳達不實資訊，應該注意的是，是否所有事項均要據實告知，學說上認為涉及當事人隱私而與交易上無關者，則為虛偽陳述亦不構成本條詐欺[101]。

2. 不作為詐欺

   不作為詐欺，需以詐欺人有告知義務為限，否則單純沉默原則上不構成詐欺。而告知義務的來源，可能有表意人之詢問、交易習

[99] 最高法院 98 年度台上字第 171 號民事判決。

[100] 「惟按民法上之詐欺，必詐欺行為人有使他人陷於錯誤之故意，致該他人基於錯誤而為不利於己之意思表示者始足當之。倘行為人欠缺主觀之詐欺故意，縱該他人或不免為錯誤之意思表示仍與詐欺之法定要件不合，無容其依民法第九十二條第一項規定撤銷意思表示之餘地。」最高法院 98 年度台上字第 171 號民事判決參照。

[101] 王澤鑑，註 6，頁 497；陳自強，註 3，頁 259。

慣、雙方約定等[102]。而明知表意人陷入錯誤，卻不告知表意人者，學說上亦認為構成不作為詐欺[103]。

而表意人因詐欺而撤銷意思表示後，是否可以對抗第三人，民法第 92 條第 2 項認為並不能對抗第三人，舉例而言：

> 案例：甲受乙之詐欺，將甲之債權移轉給乙，乙再移轉給丙，甲嗣後將債權移轉之法律行為撤銷之，對丙而言，乙仍為有權處分。

民法第 92 條第 1 項但書規定，詐欺係由第三人所為者，以相對人明知其事實或可得而知者為限，始得撤銷之。而相對人之使用人、代理人之詐欺行為，學說上認為應視為相對人所為，相對人並不能援引但書作為抗辯[104]。

二、脅迫

所謂脅迫，係指因相對人或第三人以不法危害之言語或舉動加諸表意人，使其心生恐怖，致為意思表示[105]。而手段不法者，脅迫行為有違法性，表意人自得撤銷；手段合法者，則需判斷手段與目的之關聯是否具有不法[106]。

而脅迫因為對表意人之表意自由侵害較大，因此表意人依照民法第 92 條第 2 項反面解釋，可以對抗第三人，且並無民法第 92 條第 1 項但書之適用。

三、除斥期間

按照民法第 93 條，民法第 92 條之意思表示撤銷，應於發見詐欺或脅迫終止後，一年內為之。但自意思表示後，經過十年，不得撤銷。其除斥期間較錯誤撤銷較久。

---

102 「民法第九十二條第一項所謂詐欺，雖不以積極之欺罔行為為限，然單純之緘默，除在法律上、契紙上或交易之習慣上就某事項負有告知之義務者外，其緘默並無違法性，即與本條項之所謂詐欺不合。」最高法院 33 年度上字第 884 號民事判決參照。

103 陳忠五，註 19，頁 181、182。

104 陳自強，註 3，頁 263。

105 「民法第九十二條第一項前段規定，因被詐欺或被脅迫而為意思表示者，表意人得撤銷其意思表示。所謂因被脅迫而為意思表示，係指因相對人或第三人以不法危害之言語或舉動加諸表意人，使其心生恐怖，致為意思表示而言。當事人主張其意思表示係因被詐欺或脅迫而為之者，應就其被詐欺或被脅迫之事實，負舉證之責任」最高法院 95 年度台上字第 2948 號民事判決參照。

106 「惟按民法第九十二條所指之脅迫，須為不法之脅迫，包括手段不法、目的不法及手段與目的失其平衡，而其目的在於取得不當之利益者，始足當之。」最高法院 93 年度台上字第 1810 號民事判決參照。